

0002618-24.2022.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0002618-24.2022.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002618-24.2022.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DA1736-1/2022 - DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ANDRÉ LUIZ VENTURA JÚNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, na data de 1 de julho de 2022, por volta das 14h10min, na Rua Doutor Osvaldo Brito Benedito, 10, Parque Gilberto Filgueira, nesta cidade e Comarca, adquiriu e trouxe consigo, para entrega e consumo de terceiros, 3 (três) porções de maconha, duas delas em formato de "tijolo", embaladas em inólucro formado por fita adesiva, com peso bruto de 985,75g (novecentos e oitenta e cinco gramas e setenta e cinco centigramas), substância esta causadora de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 23/25, constatadas como tal pelo laudo

pericial preliminar a fls. 18/21 e confirmadas pelo exame químico toxicológico a fls. 76/79, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/82. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 40/42). Mandado de prisão a fls. 51/53. A denúncia foi oferecida em 21 de julho de 2022 (fls. 86/88) e o réu, notificado a fls. 108, ofereceu Defesa Prévia a fls. 115/116. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 120/122). Em audiência, foram inquiridas 03 testemunhas de acusação e o réu interrogado (fls. 161/162 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 165/169). A douta Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do réu por não haver provas suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas e, em caso de eventual condenação, pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por reativas de direitos. Por fim, pleiteou pela restituição da motocicleta apreendida (fls. 174/196).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar enquanto promovia o tráfico ilícito de drogas nesta urbe. Ocorre que, durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar encontrou o acusado na companhia de Osvaldo de Souza Evangelista, em uma motocicleta, e outro indivíduo, em outra. Ao visualizar a viatura policial, este indivíduo empreendeu fuga e ANDRÉ e Osvaldo tentaram fugir, sendo abordados pelos Policiais Militares. Antes da fuga, contudo, o citado indivíduo entregou um objeto para ANDRÉ, sendo localizado durante a abordagem policial, constatando-se tratar-se de três porções de maconha, duas delas em formato de tabletes. É certo que a apreensão da droga, as declarações dos policiais militares e da testemunha Osvaldo e, sobretudo, as circunstâncias fáticas da prisão, evidenciam que o denunciado se dedica ao tráfico ilícito de drogas".

Pois bem, examinada a questão à luz da prova produzida, é forçoso reconhecer que a denúncia procede integralmente.

A materialidade do delito restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 01, auto de exibição e apreensão a fls. 07/08, boletim de ocorrência a fls. 19/21, laudo de constatação provisória a fls. 23/25, 25/28, fotografias a fls. 29/39, laudo toxicológico a fls. 76/79, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou incontestada e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Marcelo dos Santos Gambini, policial militar, em juízo, confirmou os fatos narrados em denúncia. Disse "que estavam em patrulhamento e avistaram as motocicletas. O condutor que estava sozinho na motocicleta conseguiu se evadir, mas conseguiram abordar o réu e Osvaldo. Na busca pessoal encontraram a droga com o réu e Osvaldo contou que não sabia que ele foi buscar a droga.

Entenderam que o réu estava transportando a droga. O réu nada declarou sobre os fatos. O réu já foi preso anteriormente quando adolescente, por transportar drogas".

A testemunha Diego Pires do Prado, judicialmente, policial militar, reprisou a assertiva dada por seu colega acrescentado "que, no dia dos fatos, Osvaldo contou que outro rapaz que fugiu na moto foi quem entregou a droga para André".

A testemunha Osvaldo de Souza Evangelista, em juízo, disse "que estava com o réu quando foram abordados. Disse que o réu o convidou para fumar maconha. Falou que não conhecia o rapaz da outra moto e que conhece o réu do bairro em que reside, que acredita que ele não estava trabalhando. Disse que não iria pagar André para usar drogas. Falou que não viu o indivíduo entregando drogas para André e que a polícia encontrou a droga no mato. Não chegou a ver a entrega da droga. Disse que ficou parado ao lado da moto".

O réu André Luiz, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia. Disse "que os "moleques" jogaram algo, mas não sabia o que era. Falou que os policiais encontraram a droga e mandaram ele "assumir", mas que negou a propriedade".

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (02 tijolos de maconha e uma porção grande da mesma droga), bem como do modo pelo qual estava acondicionada (ainda em tijolos).

Com efeito, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais, além da prova da materialidade.

Nesse contexto, a versão do acusado além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação, não havendo, pois, qualquer razão para desacreditá-los. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.). Ora, a inocência por ele invocada não tem amparo das provas coligidas, pois não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregar a droga apreendida ao consumo de terceiros até porque, a quantidade de entorpecente apreendido é incompatível com o uso momentâneo. E aqui, ressalte-se que a versão por ele dada é absolutamente fantasiosa, não merecendo o mínimo de credibilidade, vez que pueril e absolutamente divorciada do conjunto probatório.

Não bastasse isto, da fase inquisitiva à judicial, os depoimentos prestados pelos policiais foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

Por fim, para efeito da tipificação do delito em questão, além da quantidade do entorpecente, outras circunstâncias devem ser observadas, tais como a forma como estavam embaladas, natureza da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. In casu, a quantidade de drogas apreendidas - 02 tijolos de maconha e 01 pedra grande da mesma substância, é incompatível com o uso momentâneo o que revela, de maneira indubitável, que seu fim era a mercancia ilícita.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em

depósito ou trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, repita-se mais uma vez, essa finalidade está bem evidenciada, eis que a quantidade de droga apreendida (02 tijolos de maconha e 01 pedra grande da mesma substância, pesando mais de 900 gr) é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Neste ínterim, a alegação do réu de que é usuário de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP - Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125. Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que o réu praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ANDRÉ LUIZ VENTURA JUNIOR, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls. 1138/140), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, embora presente a atenuante da menoridade relativa, deixo de diminuir a pena em razão da impossibilidade da pena ficar abaixo do mínimo legal previsto em lei nesta fase. Não estão presentes outras agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexistente causa de aumento de pena. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E

PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020).

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, ausentes os requisitos, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 41/42. Expeça-se alvará de soltura.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo, razão pela qual, prejudicado o pedido de restituição da motocicleta formulado pela Defesa em alegações finais. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

No mais, DETERMINO a extração integral de cópias destes autos, inclusive das mídias a fls. 161/162, e posterior remessa à Delegacia Seccional de Polícia de

Avaré, a fim de que a autoridade policial delibere a respeito da instauração de inquérito policial em face de Osvaldo de Souza Evangelista pela prática do crime de falso testemunho majorado, previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal, posto que, durante sua oitiva em juízo, mudou a versão apresentada à autoridade policial, nitidamente para isentar André Luiz Ventura Junior de responsabilidade penal.

P.I.C.

Avare, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA